

1500115-22.2022.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO JOSÉ CABREIRA GOMES JUNIOR e outro

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JULIO JOSÉ CABREIRA GOMES JUNIOR e ANA BEATRIZ RUFINO MARCIANO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri (SP) - cep 11760-000

1500115-22.2022.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500115-22.2022.8.26.0633

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO JOSÉ CABREIRA GOMES JUNIOR e outro

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JULIO JOSÉ CABREIRA GOMES JUNIOR e ANA BEATRIZ RUFINO MARCIANO, imputando-lhes a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Sustenta a denúncia que, no dia 04 de março de 2022, no período da noite, na Rodovia SP 055, 371+100, Área Rural, na cidade de Pedro de Toledo, comarca de Itariri, os acusados, em unidade de desígnios, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, 4.934 porções de cocaína, com peso aproximado de 5,150kg. Narra que policiais militares rodoviários, durante fiscalização de rotina, abordaram o veículo o VW/VOYAGE, placas RML-7E33, no qual havia dois indivíduos, que se identificaram como JÚLIO e ANA BEATRIZ. Durante a abordagem, os policiais perceberam reação suspeita por parte dos réus e, por isso, realizaram busca no interior do veículo e encontraram uma sacola contendo as drogas acima descritas. O réu JÚLIO assumiu a autoria do delito e esclareceu que transportava as drogas da cidade de São Vicente e tinha como destino o município de Registro. A ré Ana

Beatriz negou a prática do crime. Contudo, foi encontrada dentro de sua bolsa uma balança de precisão.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 75/78).

Oferecida a denúncia (fls. 79/80), os réus foram notificados (fls. 126/127 e 141/142) e ofereceram defesa prévia (fls. 157/168 e 174/178).

A denúncia foi recebida (fls. 191/193).

Laudo pericial a fls. 217/219.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que ANA BEATRIZ nega saber o que estava sendo transportado, mas sabia da dívida do agiota, de cerca de 6 ou 7 mil reais, e que esta dívida iria ser paga com aquela viagem, com o transporte do que estava no carro – que era apenas a sacola – de São Vicente para Pedro de Toledo, negando, ainda, estar na posse da balança; e JÚLIO confessa a prática delitiva, tendo sido contratado para transportar a droga de São Vicente para Registro, recebendo em pagamento a quitação de uma dívida com agiota da região em que mora, de cerca de R\$ 5.500,00.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, ressaltando a suficiência probatória da autora mesmo de ANA BEATRIZ, com valoração na fixação da pena da atenuante da confissão para JÚLIO e afastamento da figura privilegiado ante a quantidade de droga, com regime inicial fechado (fls. 265/272).

A defesa técnica de JÚLIO suscita a nulidade da prova pericial ante a quebra da cadeia de custódia, pois a droga pesada pelo perito tinha 4kg a menos do que a droga apreendida e a nulidade da busca veicular pela inexistência de fundada suspeita. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo, a consideração da confissão e a aplicação da figura privilegiada, com regime inicial aberto e substituição por restritiva de direitos (fls. 286/309).

Já a defesa de ANA BEATRIZ pugna por sua absolvição, dizendo que o nervosismo constatado pelos policiais é natural, sobretudo em jovens que acabaram de fazer uso de droga, subsidiariamente, requerendo a aplicação da figura privilegiada (fls. 311/322).

A folha de antecedentes atualizada foi acostada a fls. 213/214 e há certidão de distribuição a fls. 225/226 e 228/229.

Fundamentação

Preliminares

Afasto-me, de início, a alegada nulidade na prova pericial por suposta divergência entre o peso da droga apreendida e o apurado pelo expert. Como está expresso no laudo, constatou-se no pacote lacrado 1.073,1g de massa líquida de cocaína, nos 4.992 “microtubo(s) plástico(s) do tipo 'Eppendorf'”. Algo diverso é o peso bruto do produto e da substância, sabidamente superior ao peso da substância entorpecente ilícita, inclusive conforme o grau de pureza com o que comercializada. A divergência, que é irrisória e compreensível, se dá na quantidade de microtubos contados pela autoridade policial (4.934) e pela equipe técnica (4.992).

Depois, de acordo com os artigos 240, parágrafo 2º, e 244 do Código de Processo Penal, autoriza-se a busca pessoal, independentemente de mandado judicial, no curso de busca domiciliar. Ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Em diversos termos, quando houver indícios suficientes de que a pessoa porte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, e cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato ou qualquer outro elemento de convicção.

É certo que “os arts. 240, § 2.º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Esta fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações pessoais acerca do “sentimento”, “intuição” ou o “tirocínio” do agente policial que a executa.” (REsp 1953889/SP, Rel. Min. Laurita

Vaz, Sexta Turma, j. 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

No caso, conforme atestado pelos policiais militares, foi feita a fiscalização de trânsito de rotina, a partir de justificado perfil na atividade delitiva, de veículos sedan, ocupado por casais, com placa indicativa de se tratar de veículo alugado ou de fora do Estado. Isto durante a noite, por volta das 22h, segundo constou do registro policial. Durante a checagem dos documentos, e ainda de fora do veículo, perceberam incomum nervosismo e o saco em que depois encontrada a droga – no banco traseiro, a plena vista do agente policial. Ainda antes de revistarem o veículo, disseram os agentes que JÚLIO confessou estar transportando droga, o que não negou em seu interrogatório.

Enfim, tudo o que, segundo se crê, dava fundadas razões para a realização da revista pessoal e veicular, não havendo qualquer nulidade a reconhecer nas provas daí derivadas.

Existência e Autoria

No mais, a existência da ação criminosa restou parcialmente demonstrada pelas provas documental, pericial e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de cocaína.

A própria quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros. Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

E a autoria delitiva também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos, somando-se à confissão do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Com efeito, as testemunhas ouvidas atestaram ter sido o acusado JÚLIO abordado na condução de veículo automotor transportando as drogas para outro Município.

O policial militar Rionaldo deu sinal de parada ao veículo Voyage, cor cinza, e, durante os procedimentos de vistoria veicular, juntamente com o Cabo Lima, localizou uma sacola no banco traseiro. Questionado sobre seu interior, JÚLIO confirmou se tratar de entorpecentes e, indagado, disse que estava transportando de São Vicente para Registro e que iria quitar uma dívida com agiota com a quantia a ser recebida. No momento da ordem de parada, quando da abordagem, JÚLIO apresentou um nervosismo incomum para a fiscalização de trânsito. ANA BEATRIZ, passageira, também estava nervosa. Antes de abrirem a sacola grande, perguntaram e JÚLIO

confirmou se tratar de droga. O saco era grande, opaco, e não dava para ter certeza sobre seu conteúdo, razão de terem perguntado se haveria algum tipo de ilícito antes de abrirem. Quanto a ANA BEATRIZ, ela se mostrou bem apreensiva e, depois de constatar se tratar de droga, tiveram até de acalmá-la. Ela negou saber que JÚLIO estava transportando, mas conhecia a dívida com agiota que seria quitada. Ambos foram ouvidos juntos antes da condução à Delegacia. Na bolsa de ANA BEATRIZ encontraram, se não se engana, um cigarro de maconha, somente. Perguntado sobre a apreensão de uma balança, disse que era uma balança pequena e que não sabia se estava envolvida com a situação ou não, até porque não suportaria a pesagem de toda a droga que era transportada na sacola. Não conseguiram atrelá-la ao entorpecente em si. Foi uma fiscalização de trânsito de rotina e deram a ordem de parada do Voyage como o fizeram com outros veículos na mesma situação. A abordagem foi idêntica a todos os demais veículos fiscalizados. Disse que a abordagem se deu na barreira do posto policial, com cones e passagem em velocidade reduzida dos veículos da rodovia. O sinal de parada foi dado pelo Cabo Lima e, na sequência, JÚLIO obedeceu e fez a parada. Parado, o Cabo Lima seguiu até o veículo e estava próximo, fazendo a função de segurança, de supervisor da abordagem. Estava a cerca de 1,5m-2m do condutor e viu, como sinais de nervosismo, tremor e fala interrompida, trêmula, em especial a partir de quando indagado sobre a sacola. Não há câmera de monitoramento no local. Na abordagem, JÚLIO afirmou que estava transportando, mas não assumiu a propriedade da droga; disse, porém, que ANA BEATRIZ não sabia do transporte da droga, apenas da dívida de JÚLIO com terceiro. O cigarro de maconha e a balança estavam no interior da bolsa de ANA BEATRIZ. A abordagem se deu de forma aleatória, geralmente de veículos com casal, motocicletas, caminhão. O motivo da abordagem no caso é que era um veículo sedan, contendo um casal, e, em geral, alugados – mas não se recorda se era esse o caso do Voyage dos réus, embora semelhante ao perfil dos veículos para tanto utilizados. O policial Thiago disse que estava em operação em frente à base e deu sinal de parada ao veículo, em especial porque era de outro Estado, diante da primeira letra da placa. A suspeita decorreria da utilização de veículos de outro Estado como uber e, em geral, para o transporte de drogas. O veículo não tinha insulfilm e visualizaram a sacola em cima do banco traseiro. Perguntado sobre o que estava transportando, ele prontamente informou se tratar de droga. Foram, então, analisar e viram os eppendorfs de cocaína. JÚLIO disse que transportava a droga de São Vicente para Registro e que a dívida com um agiota morreria se fizesse o transporte. Na abordagem inicial, pedindo a documentação, JÚLIO gaguejou, o que gerou a dúvida. Olhando melhor, ainda por fora do veículo, foi possível ver a sacola no banco traseiro, o que estava escancarado. A sacola era grande. Com ANA BEATRIZ, se não se engana, foi encontrado um cigarro de maconha, um deschavador e uma balança muito pequena. Informalmente, ANA BEATRIZ falou que não sabia de nada, apenas que JÚLIO tinha uma dívida com um agiota. A base é toda “conificada” para que haja a redução da velocidade e não há câmera de monitoramento. O depoente é quem deu o sinal de parada e JÚLIO encostou normalmente. Pediu os documentos e Rinaldo fez a segurança, ficando a cerca de 1,5m ou 2m de distância de si. A placa do veículo já era modelo MERCOSUL. JÚLIO gaguejou, mas não se recorda se ele tremeu. Como o carro não tinha insulfilm escuro, mesmo com os vidros fechados viu a sacola. Assim que pegou o documento visualizou, imediatamente, a sacola no banco traseiro, ato contínuo indagando JÚLIO o seu conteúdo – de pronto dizendo se tratar de droga. A balança não era a de um chaveirinho, mas tinha o tamanho de uma calculadora, de cerca de 15cm. ANA BEATRIZ era apenas passageira do veículo e, informalmente, disse não ter qualquer conhecimento sobre a droga. Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Contudo, não restou demonstrada a conduta atribuída a ANA BEATRIZ. Com efeito, era ela apenas a passageira do veículo e a droga estava no banco traseiro, já por isto não podendo estar transportando a droga. Ainda que se possa concluir estivesse bem ciente do conteúdo da sacola ante todo o contexto que cerca o transporte por JÚLIO,

nada indica tenha sequer auxiliado, induzido ou instigado JÚLIO na empreitada criminosa, justificada sua presença, ali, por seu relacionamento amoroso com o motorista. O só fato de ser passageira é insuficiente para responsabilizá-la, penalmente, pela conduta do motorista e dono da droga.

A propósito, embora deva se receber com ressalvas seus depoimentos, as testemunhas de defesa disseram que ANA BEATRIZ possui ocupação lícita.

Caique, amigo de JÚLIO e ANA BEATRIZ, há quatro ou cinco anos e inicialmente de ANA BEATRIZ, sabe que ela trabalha de segunda a sábado e, segundo sabe, JÚLIO trabalha de uber. Desconhece qualquer envolvimento de ANA BEATRIZ com tráfico de drogas. Segundo sabe, ANA BEATRIZ não consome drogas.

Rosemary, cunhada de ANA BEATRIZ, disse que nada sabe sobre o transporte de droga e a conhece há 6 anos. ANA BEATRIZ trabalha durante o dia em um carro de lanche e de noite com marmitex. Conhece JÚLIO e nada sabe que o desabone. Trabalha como uber. Segundo sabe, ANA BEATRIZ nunca se envolveu com tráfico ou com algum problema na Justiça.

Em suma, a este respeito, o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando dúvida quanto à responsabilidade penal da acusada ANA BEATRIZ. Assim, não afastada a presunção de inocência a todos assegurada pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, corolário de um Estado Democrático de Direito, impõe-se o afastamento da pretensão neste particular.

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

A acusação não logrou demonstrar que o agente seja reincidente, tenha maus antecedentes, se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual aplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Ao contrário, o único elemento nesse sentido foi a folha de antecedentes, que indica a primariedade do acusado.

Note-se que a apreensão de quantidade não módica de droga em poder do acusado não é indício suficiente para, isoladamente, permitir se conclua que a acusada se dedica às atividades criminosas, pois daí não se extrai conclusão segura (STF, HC 138138, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016), a menos que se trate de quantidade realmente exorbitante ou que haja outros indícios, o que não é o caso.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta Maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, *Fermín Ramírez vs. Guatemala*, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas negativamente, diante da quantidade expressiva, superior ao suprimento anual de um usuário de droga, nos termos já adotados.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social, desfavorável a natureza e quantidade da droga e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 10 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal).

Por conseguinte, observada a preponderância dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, atenuo a pena em 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato.

Por fim, na terceira etapa, reduzo a pena de 2/3, no patamar máximo do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, do qual não se extrai critério seguro para

gradação, em ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal), evitando-se, ainda, inadmissível bis in idem na dupla valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal combinado com o artigo 42 da Lei 11.343/06) na primeira e na terceira etapas.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 2 anos, 9 meses e 10 dias.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 1.000 dias-multa, fixo a pena de multa final em 278 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 49, § 1º, do CP, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena igual ou inferior a 4 anos, da primariedade dos acusados e das circunstâncias judiciais que não se mostram desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal).

É inaplicável ao tráfico privilegiado a previsão constante do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, porque não se trata de crime equiparado a hediondo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), ao que se curvou o Superior Tribunal de Justiça revendo a tese fixada em recurso repetitivo e cancelando a sua Súmula 512, para assentar que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Substituição e sursis

Diante das circunstâncias judiciais em torno do crime e do acusado (artigos 44, inciso III, e 59, inciso IV, do Código Penal) e do preenchimento dos requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade superior a 1 ano por duas restritivas de direitos, na forma do artigo 44, parágrafo 2º, do Código Penal, lembrando que o Senado Federal suspendeu a execução, nesta parte, da vedação disposta no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 após decisão do Supremo Tribunal Federal.

A fim de atender às finalidades preventiva e retributiva da sanção penal e permitir, na medida do possível, a restauração dos efeitos do delito na comunidade, determino a substituição por prestação de serviços à comunidade ou a entidades pública (artigo 46 do Código Penal), a ser especificada e adaptada quando da execução (artigos 148 e 149 da Lei de Execução Penal), e pela interdição temporária de direitos do artigo 47, inciso III, do Código Penal, ficando o acusado com a suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo tempo da pena privativa de liberdade. Note-se que há vinculação entre a suspensão do direito de dirigir e as circunstâncias em que cometido o crime, com o transporte da droga de uma cidade a outra.

Indicada a substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44 do CP), é incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP), até porque aquela se mostra mais propícia à rápida ressocialização do acusado.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar JULIO JOSÉ CABREIRA GOMES JUNIOR à pena de reclusão de 2 anos, 9 meses e 10 dias, em regime inicial aberto, e a 278 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-

mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa de diminuição do parágrafo 4º do mesmo dispositivo, substituída pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e de interdição temporária do direito de dirigir; e absolver ANA BEATRIZ RUFINO MARCIANO da acusação da prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, o que faço nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e revogo a prisão preventiva, porque incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado a JULIO. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade.” (HC 193996 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020). No mesmo sentido: HC 136397, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016.

Considerando a necessidade de garantir a ordem pública e, sobretudo, de assegurar a aplicação da lei penal, é necessário, adequado e suficiente a concessão da liberdade provisória a JÚLIO mediante a determinação de a) comparecimento perante a autoridade policial ou judicial todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento; b) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização do Juízo; c) mudar de endereço sem prévia autorização do juízo. Tudo na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, expeça-se, com urgência, os alvarás de soltura clausulados.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Encaminhe-se o ofício em separado com as informações solicitadas pelo Tribunal de Justiça (HC 2256424-78.2022.8.26.0000).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal); ao condenado em regime inicial fechado, expeça-se o mandado de prisão, se o caso, e a guia de recolhimento definitiva (artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010); ao condenado em regime inicial semiaberto, expeça-se o mandado de prisão, se já estiver preso, e a guia de recolhimento definitiva e encaminhe-se ao juízo da execução competente (Resolução CNJ 474/22 e Comunicado CG 628/22); ao condenado em regime inicial aberto, intime-se para comparecimento à audiência admonitória, se estiver em liberdade, e expeça-se o mandado de prisão específico (Comunicado CG 1356/16).

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Itariri, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA